

1500599-38.2021.8.26.0062

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas é de rigor.

Ademais, o tráfico de drogas, nas modalidades "trazer consigo", "manter em depósito", "guardar" e "transportar", prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ - Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade, cabalmente comprovada nos autos pelos depoimentos já mencionados, assim como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500599-38.2021.8.26.0062 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500599-38.2021.8.26.0062

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214867/2021 - DEL.POL.BARIRI, 19510137 - DEL.POL.BARIRI, 1000/21/202 - DEL.POL.BARIRI, 2214867 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON RODRIGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

WELLINGTON RODRIGUES e MICK WELLINGTON DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente no dia 09 de agosto de 2021, por volta das 16hs, na rua Antônio Spalone, 197, Yang 3, parque Vale do Tietê, nesta cidade e comarca de Bariri, ambos os réus, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico ilícito de drogas, 4 (quatro) "kits" contendo ao todo 64 (sessenta e quatro) eppendorfs contendo a cocaína, totalizando 39,65g (trinta e nove gramas e sessenta e cinco centigramas) e 2 (duas) porções de cocaína na forma de crack totalizando 0.19 g (dezenove centigramas), bem com, WELLINGTON RODRIGUES, supostamente, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 1.342 (um mil e trezentos

e quarenta e dois) eppendorffs contendo a cocaína, totalizando 789.55g (setecentos e oitenta e nove gramas e cinquenta e cinco centigramas).

Defesa prévia de WELLINGTON RODRIGUES, às fls. 203/218; e de MICK WELLINGTON DA SILVA, às fls. 238/240.

A denúncia foi recebida em 16/12/2021, e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 255/256).

Em instrução, foram ouvidas cinco testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais mediante memoriais, o Ministério Público, sustentando estar provada a materialidade e autoria, requereu a condenação de ambos os réus, nos termos da denúncia (fls. 365/382).

O réu Wellington Rodrigues, nas alegações finais de fls. 383/397, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da pena mínima e o reconhecimento do direito à benesse do art. 33, §4º, da LD, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O réu Mick Wellington da Silva, por sua vez (fls. 403/409) pleiteou a absolvição por falta de provas, apregoando, em síntese, insuficiência e fragilidade do conjunto probatório; bem como a revogação da prisão preventiva.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito se encontra formalmente em ordem, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, ainda, nulidade a sanar, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, em relação a ambos os réus.

A existência do fato (materialidade) está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 09, boletim de ocorrência de fls. 19/22 e fls. 55/57, auto de exibição e apreensão de fls. 17, laudo definitivo da droga apreendida às fls. 335/342, e, ainda, pela prova coligida em Juízo.

Passo, pois, ao exame da autoria.

A testemunha Emerson Luís Albranti, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento. Em uma esquina, visualizaram Wellington sair com seu carro, juntamente com um passageiro. Wellington foi em direção à viatura, que não havia visto. Quando viu a viatura, Wellington se assustou e começou a empreender fuga. De imediato, o reconheceu. Também reconheceu Mick. Na fuga, Wellington e Mick seguiram na contramão. Os policiais seguiram em perseguição. Posteriormente, “começaram a jogar saquinhos de pino azul”. Em acompanhamento, ele, testemunha, pediu apoio policial, para que outra viatura recolhesse a droga. As drogas estavam sendo jogadas de ambas as janelas, tanto do passageiro quanto do condutor. Os policiais continuaram o acompanhamento. Wellington bateu a roda em uma guia e saiu em fuga a pé. Conseguiram detê-lo. Wellington resistia. Feita a busca pessoal, em Wellington foram localizadas mais duas pedras de crack e mais oito porções de cocaína. Com o restante das drogas recolhidas, foram apreendidos 64 pinos de cocaína. Wellington disse que não sabia quem estava com ele. Foram até a residência de Wellington, onde Wellington franqueou o acesso e mostrou onde estava a droga; e lá encontraram mais 1.342 eppendorfs contendo cocaína, que estavam dentro de uma caixa de isopor, em cima do guarda-roupa. Os eppendorfs eram da mesma cor. Dias antes, Wellington tinha sido apresentado no CPJ, mas não ficou preso, pois acredita que não houve flagrante naquela oportunidade. Todos os eppendorfs, localizados na residência e dispensados do veículo, eram da mesma cor. Wellington é conhecido como um grande traficante da região de “Igrejinha”. Receberam várias informações a esse respeito, inclusive de Mick estava trabalhando junto. Conhecia os dois. Conseguiram “pegar” só Wellington. “Igrejinha” é um ponto de tráfico na Comarca. Já viu os dois juntos na biqueira da “Igrejinha”. Ao que se recorda, Mick não trabalha. Wellington colaborou com os policiais, dizendo que havia mais drogas na casa e mostrando onde elas estavam, na caixa de isopor. Receberam denúncias anônimas sobre traficância praticada por

Wellington. Quem recolheu as drogas jogadas pelo veículo foi o policial Evandro. Se não se engana, viu 4 pinos. Posteriormente, questionado pela Defesa de Mick, declarou que, na verdade, conforme constou em seu depoimento na Delegacia de polícia, viu as drogas serem arremessadas do interior do veículo do lado do motorista. Não se recorda se Mick estava de boné ou não. Outra viatura, depois, foi na casa de Mick, mas não se recorda bem. Não foi buscada droga dentro da residência de Mick, e o que ocorreu é que a mãe dele compareceu à Delegacia. Não se recorda se foi feito reconhecimento fotográfico na Delegacia. Durante a perseguição, a viatura ficou à distância de aproximadamente 20 metros do veículo, e as ordens de parada não eram obedecidas.

A testemunha Anderson Luís Bettini de Moraes, policial militar, declarou que estava em patrulhamento com o policial Emerson, quando avistaram um gol bolinha saindo da residência de Wellington, já sabiam que ele morava ali. Identificaram que Mick estava no veículo. Quando Wellington percebeu que a viatura estava atrás, empreendeu fuga, desobedecendo sinalizações e fugindo pela contramão. Avistaram as drogas sendo jogadas pelas janelas. Continuaram em perseguição. Pediram apoio à outra viatura. Em uma curva, Wellington bateu em uma guia, ambos saíram do veículo e começaram a correr. Conseguiram deter Wellington, Mick conseguiu fugir. No bolso de Wellington havia mais um kit de droga, “epperdorfs” de cocaína e “crack”, como aqueles que foram jogados. Wellington confessou que tinha mais droga em casa. Deslocaram-se até o local, Wellington franqueou o acesso e indicou onde estavam as drogas, em uma caixa de isopor em uma guarda-roupa. Wellington “desconversou” sobre Mick. A droga encontrada na residência era da mesma cor daquela jogada na via. Identificaram Wellington e Mick de pronto, já tinham informações de envolvimento na traficância. Já haviam abordado ambos em situações anteriores. Wellington foi apresentado em Jaú em situação anterior, mas não ficou preso. Ao que sabe, Mick não trabalha. Wellington falava que trabalhava com o pai dele no sítio. Wellington comparecia na biqueira, quase todo dia, de madrugada. Era o motorista da viatura e via o condutor jogando drogas, mas se via sair entorpecentes pelas duas janelas. Não viu o braço do carona jogando drogas. Não lembra que roupa Mick usava; não lembra se ele estava de boné ou não.

A informante Rosimeire Cristina da Silva, mãe de Mick, declarou que, no domingo, os policiais “pegaram” Mick. Na segunda-feira, ele estava trabalhando, e chegou à tarde do serviço, e os policiais foram até a sua casa. Foram pegos de surpresa. Mick lhe disse que iria se esconder, pois a polícia o tinha capturado no domingo, e iria atrás de novo na segunda, injustamente. Na segunda-feira, Mick estava trabalhando, em Itapuí, como servente de pedreiro, com Paulo. Reconhece “Paulinho” e Mick na foto de fl. 241. Reconhece “Mick” à fl. 245 também. Mick disse que iria fugir porque estava com medo de ser preso injustamente. Mick não conhece Wellington e nunca citou o nome dele.

A testemunha Paulo César Domingues declarou que foi casado com a tia de Mick e tem uma relação próxima com ele. Quando tem serviço, Mick trabalha junto com ele [testemunha]. No dia em que houve problema com a Polícia, Mick estava trabalhando junto, em Itapuí. Na segunda-feira, trabalhou junto com Mick até as 17h00min. Mick trabalhou, na segunda-feira, o dia todo.

O réu Wellington, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva. Declarou que morava em um sítio, a situação começou a ficar ruim, veio morar “na cidade”. Veio a pandemia de COVID e começou a enfrentar dificuldades financeiras. Aceitou a proposta que lhe fizeram, havia começado a vender os entorpecentes uma semana antes. Facilitou a entrega das drogas para os policiais, e correu porque ficou com medo. A droga que os policiais encontraram estava com ele. Não conhecia o rapaz que com ele estava. Não conhece o corréu e não o reconhece como a pessoa que estava com ele no carro. Quem estava com ele no carro era pessoa desconhecida, a quem deu carona. O carro era seu. Não se recorda quem jogava as drogas pela janela. Os policiais o abordaram, tentou correr e tentou reagir, mas não conseguiu. Disse aos policiais que havia droga em casa, em cima do guarda-roupa, na caixa de isopor. Ao que se recorda, tinha mais 1.342 pinos em casa. A droga estava em sua casa há uma semana. Conheceu, em Bariri, a pessoa que lhe ofereceu a droga.

Já o réu Mick, em seu interrogatório, declarou que, em um domingo, a Polícia lhe

capturou, o levaram para uma casa abandonada e “acharam droga, só que me liberaram” (sic). Não sabe se está respondendo processo por esse fato. Não tem “nada a ver” com os fatos narrados na denúncia. Estava trabalhando em Itapuí. Já viu Wellington na rua, mas nunca conversou com ele. Estava trabalhando com Paulo César. De Itapuí até o local onde mora, dá uns 20, 25 minutos. Quando saiu do trabalho, foi direto à casa de sua avó, pois algumas pessoas estavam falando que a Polícia estava atrás dele. Quem lhe contou isso foram “umas meninas”, só conhecia “de vista”. Sua tia lhe falou que a Polícia fora atrás dele, e sua mãe estava trabalhando. Ligou para a mãe, e ela foi até a Delegacia saber o que houve; na realidade, acredita que foi até a tia quem ligou para a sua mãe. Então, ficou com medo de ser preso e fugiu. Não voltou mais ao trabalho.

Pois bem.

O conjunto de provas coligido judicialmente revela, com segurança, a autoria delitiva de Wellington e Mick.

Confrontando a confissão de Wellington com os demais elementos de prova, analisados em conjunto (arts. 197 e 200 do CPP), notadamente depoimentos das testemunhas policiais, não há dúvidas de que, efetivamente, trazia consigo e mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos, com a finalidade de entregá-los a terceiros. Vale notar que o próprio réu confessou que os entorpecentes eram destinados à comercialização, apregoando o enfrentamento de dificuldades financeiras que o compeliram a tanto. Ademais, Wellington, conforme declarou em seu interrogatório, colaborou com as diligências policiais e, conduzindo os policiais até a sua casa, franqueou-lhes o acesso e indicou-lhes o local onde depositava o restante dos entorpecentes apreendidos.

Com relação à Mick, a tese de autodefesa, relacionada ao suposto “álibi”, é fantasiosa e não merece prevalecer, como se nota do cotejo do teor de seu interrogatório com as declarações de sua mãe e da testemunha Paulo.

Veja-se que a mãe de Mick, Rosimeire, declarou que, na segunda-feira, Mick estava trabalhando, e chegou à tarde, tendo ele lhe dito que iria fugir porque estava com medo de ser preso injustamente.

Entretanto, o próprio réu declarou que, ao chegar à Bariri, foi imediatamente à casa da avó, tendo a sua tia conversado com a sua mãe – versão diferente, portanto, à da genitora.

Demais disso, é pouco crível supor que pessoas que apenas lhe conheciam de vista o teriam avisado sobre as atividades policiais no dia dos fatos.

As declarações da informante e da testemunha Defesa (mãe de Mick e Paulo, anteriormente casado com a tia do réu) revelam-se frágeis e contraditórias, não possuindo a necessária credibilidade; evidenciando-se a ausência de isenção de ânimo, mormente em razão das relações familiares já citadas.

Por outro lado, os depoimentos de ambos os policiais foram uníssonos, seguros e coesos quanto à identificação de Wellington e Mick no veículo do qual as drogas foram dispensadas. As testemunhas Emerson e Anderson foram firmes ao apontarem a identificação de ambos os réus no veículo – seguido, de forma próxima, pela viatura policial durante a perseguição -, até porque já lhes eram, anteriormente, conhecidos.

Destaco, ainda, terem as testemunhas afirmado que, após Wellington ter colidido em uma guia, ambos os réus desceram do veículo e empreenderam fuga a pé, não havendo dúvidas, portanto, de que mantiveram contato visual com os denunciados por tempo suficiente para, mais uma vez os identificarem.

Nesse contexto, o álbi trazido por Mick revela-se discrepante da prova testemunhal, nada havendo nos autos a indicar, com o mínimo de credibilidade, que as testemunhas Emerson e Anderson tenham mentido em juízo, procurando falsamente incriminá-lo. Da mesma forma, confrontados pelos demais elementos de prova, não merece guarida a declaração de Wellington, de que a pessoa que o acompanhava no veículo era terceiro desconhecido. Outrossim, tampouco se pode concluir que as fotografias de fls. 241/242 tenham sido feitas no dia dos fatos.

Assim, tem-se que o conjunto de provas revela que tanto Mick quanto Wellington, juntos, transportavam e traziam consigo entorpecentes, destinados à entrega de terceiros, que buscaram ocultar atirando pela janela do veículo, de forma a impedir

a apreensão do corpo de delito à vista da aproximação da viatura.

Destaco, outrossim, terem as testemunhas Emerson e Anderson declarado que o veículo em que os réus estavam saíra da residência de Wellington quando, avistada a viatura, iniciou-se a fuga. Como se vê, ambos os réus na residência de Wellington instantes antes, local onde o último depositava o restante das drogas, e, de lá, saíram juntos transportando os entorpecentes jogados pelo veículo.

Quanto ao fato de as testemunhas Emerson e Anderson não se recordarem das vestes utilizadas por Mick, tal circunstância em nada afasta a credibilidade de seus relatos, até porque pequenos lapsos de memória, referentes a sinais pessoais dos acusados, são ínsitos ao transcorrer do tempo, especialmente considerando a realização da instrução vários meses após o flagrante. No mais, em Juízo, as testemunhas, como dito, foram firmes ao indicarem que conheciam Mick e o identificaram no dia dos fatos. Vale notar que não há dúvida de que Mick fora abordado no dia anterior (fato reportado tanto pelo réu quanto pelas testemunhas), o que corrobora a declaração de que já era mesmo conhecido dos meios policiais. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, porquanto são testemunhas compromissadas assim como as demais, inexistente razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de seus relatos.

Nesse sentido, o TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Ademais, inexistente nos autos prova de que tivessem a intenção de prejudicar os acusados, imputando-lhes crime não cometido, independentemente de Mick ter sido abordado no dia anterior.

No mais, o auto de exibição e apreensão de fls. 17 comprova que os entorpecentes estavam acondicionados em vários "ependorfs" (com iguais características tanto os dispensados do veículo quanto os apreendidos na residência de Wellington), ao modo usual das drogas destinadas a comercialização e entrega a terceiros, e não apenas a consumo próprio, tese de defesa sequer aventada.

Não bastasse, foram apreendidas drogas de naturezas diversas (cocaína e cocaína em forma de "crack"), fato que, somado às circunstâncias acima indicadas, bem evidencia a destinação à entrega para consumo de terceiros, como, aliás, declarado por Wellington.

E mais, a expressiva quantidade apreendida também revela tal finalidade. Afinal, foram apreendidos quatro "kits" contendo ao todo 64 (sessenta e quatro) "ependorfs" contendo a cocaína, totalizando 39,65g (trinta e nove gramas e sessenta e cinco centigramas) e 2 (duas) porções de cocaína na forma de crack totalizando 0.19 g (dezenove centigramas), mais 1.342 (um mil e trezentos e quarenta e dois) "ependorfs" contendo a cocaína, totalizando 789.55g na residência de Wellington.

Portanto, e à luz dos parâmetros do art. 28, §2º, da Lei de Drogas ("Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."), descabido falar de destinação exclusiva a consumo pessoal.

Como consequência, a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas é de rigor.

Ademais, o tráfico de drogas, nas modalidades "trazer consigo", "manter em depósito", "guardar" e "transportar", prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ - Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade, cabalmente comprovada nos autos pelos depoimentos já mencionados, assim como, repiso, pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias, de naturezas distintas, tudo de modo a facilitar a entrega a terceiros.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS SEPARADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014)." (STJ. HC 496.536/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

No mais, presentes a materialidade e a prova segura da autoria, cumpre examinar as questões relativas à tipicidade penal.

Nesse caminho, registro, desde já, ser de rigor a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor de Wellington, conforme Súmula 630 do STJ ("A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."). Já quanto ao privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o dispositivo prevê: "§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.".

No caso em tela, ambos os réus são primários (fls. 304/307).

Nessa quadra, consoante definido pelo STF, 2ª Turma, no HC 154.694/SP, para fins do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, milita em favor dos réus a presunção de que são primários, possuem bons antecedentes e não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa. O ônus de provar o contrário é do Ministério Público, o que não ocorreu no presente caso.

Impende asseverar que, ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, na linha do entendimento do STF, a quantidade de droga, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 138715/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23.05.2017, Informativo 866).

No mesmo sentido, tem o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, conforme HC 726.726/MG (relator Min. João Otávio de Noronha). No REsp n. 1.887.511/SP, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pelo Min. João Otávio de Noronha, especificamente com relação à natureza e quantidade das drogas apreendidas, definiu as seguintes balizas:

- a) Devem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena, pela necessidade de observância dos vetores indicados no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 como preponderantes;
- b) Não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena; e
- c) Supletivamente, podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Também ficou definido que quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não valoradas na primeira etapa, para fixação da pena-base, podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Portanto, em homenagem à segurança jurídica e observância dos precedentes, cumpre

reconhecer o privilégio, pois não há, no caso dos autos, elementos idôneos e concretos que denotem dedicação dos réus à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa (o que não se confunde com o fato de serem conhecidos dos meios policiais e avistados em “biqueira”, sem elementos idôneos que comprovem a frequência a locais de tal espécie para ali praticarem uma das condutas do art. 33 da LD). O fato de os réus serem conhecidos dos meios policiais, por “denúncias anônimas”, não é o bastante em termos de standard probatório existente no Processo Penal.

Em síntese, diante de todos esses fundamentos, é imperativa a aplicação, em favor de ambos, do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

No mais, suficientemente comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e não se verificando a ocorrência de causa ou circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, é de peremptória a responsabilização penal.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Réu WELLINGTON RODRIGUES

Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Assim, em atenção às circunstâncias do caso em tela, deve a sanção-base ser aplicada acima do mínimo legal, considerando que o réu transportou e trazia consigo entorpecentes de naturezas distintas, incluindo cocaína e cocaína na forma de “crack”, de natureza muito mais gravosa à saúde pública do que outras substâncias. Registro que a natureza da droga será considerada apenas neste momento da dosimetria, em conformidade com o entendimento 6ª Turma do STJ, in verbis: “(...) a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o quantum de redução” (STJ. AgRg no HC 605.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Da mesma forma, a quantidade da substância apreendida exige valoração em seu desfavor, já que foram apreendidos 1.342 (um mil e trezentos e quarenta e dois) eppendorffs contendo a cocaína, totalizando 789.55g, mais 4 (quatro) “kits”, contendo ao todo 64 (sessenta e quatro) eppendorfs contendo a cocaína, totalizando 39,65g (trinta e nove gramas e sessenta e cinco centigramas) e 2 (duas) porções de cocaína na forma de crack totalizando 0.19 g (dezenove centigramas). Apenas como referencial, cumpre trazer à baila a tabela esquemática presente no Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre o Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, elaborado pela Secretaria do Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná no ano de 2014, citada no julgamento do RE 635.659, Repercussão Geral, de Rel. do Min. Gilmar Mendes (cujo objeto é a análise da constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006).

O estudo técnico mencionado aponta, apenas como um norte que a quantidade média para uso individual de “cocaína” (sal) é de 0,2 gramas, consoante a mesma Portaria. Note-se, portanto, que a quantidade de cocaína apreendida, exacerbada, possibilitaria o consumo de terceiros por longo período, aprofundando-se de forma relevante o dano à saúde pública.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

O réu não possui Maus antecedentes.

Os motivos que o levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As consequências foram normais.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. Não há falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago). Logo, de rigor o aumento da pena-base, de modo que, considerando duas circunstâncias judiciais negativas (natureza e quantidade dos entorpecentes), aumento a pena-base em 1/6 para cada, e fixo a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase do cálculo, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), e não estão presentes agravantes.

Assim, atenuo a pena em 1/6, para fixá-la, na etapa intermediária, em 5 anos, 6 meses e 20 dias; e 555 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento. Por outro lado, cabível a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Quanto ao aspecto, a redução se impõe no máximo patamar, isto é, 2/3, não se visualizando circunstâncias excepcionais que imponham a modulação do redutor em parâmetro mais prejudicial.

Reitero, aqui, que a escolha de tal fração se dá em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo o qual "Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base." (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). Logo, aumentada a pena-base em razão da quantidade de drogas, a modulação do privilégio em patamar distinto implicaria bis in idem, à míngua de circunstâncias excepcionais que justifiquem a escolha da fração em montante diverso do máximo.

Portanto, diminuo a pena em 2/3 e a fixo, definitivamente, em 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão, e 185 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Réu MICK WELLINGTON DA SILVA

Na primeira fase, em atenção ao 42 da Lei de Drogas, deve a sanção-base ser aplicada acima do mínimo legal, considerando que o réu transportou e trazia consigo entorpecentes de naturezas distintas, especialmente cocaína na forma de "crack", de natureza anormalmente lesiva à saúde pública.

A quantidade de drogas que trazia consigo (39,65g de cocaína e 0.19 g de crack) não se revela expressiva, não impondo negatificação.

Nada a considerar quanto à conduta social e a personalidade.

O réu possui maus antecedentes.

Os motivos que o levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As consequências foram normais.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

Não há falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago).

Logo, presente uma circunstância judicial negativa (natureza dos entorpecentes), aumento a pena-base em 1/6, e fixo a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase do cálculo, ausentes atenuantes ou agravantes, estabilizo a pena no mesmo quantum anterior.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento.

Por outro lado, cabível a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei

de Drogas, no máximo patamar, isto é, 2/3, não se visualizando circunstâncias excepcionais que imponham a modulação do redutor em parâmetro mais prejudicial.

Portanto, diminuo a pena em 2/3 e a fixo, definitivamente, em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Disposições comuns
Regime inicial

Para a fixação do regime inicial, cumpre observar os critérios do art. 33, §§2º e 3º e art. 59, todos do Código Penal.

No caso dos autos, ambos os réus são primários e não há adequação na fixação de regime inicial mais gravoso, mormente ante o quantum da pena.

Estabeleço, pois, para ambos os réus, o regime inicial ABERTO, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal

Não há falar em aplicação da regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal (detração penal) neste momento, porquanto o benefício não se confunde com progressão de regime; e, ainda, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

De início, saliento que, no julgamento do HC 97.256, o Tribunal Pleno do STF, por maioria, considerou inconstitucionais os dispositivos da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) que vedam a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Posto isso, os réus preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena corporal de Wellington e Mick por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, segunda parte, e §4º, do CP) para cada, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, §4º, do CP); e, b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo (art. 45, §1º, do CP), em favor de entidade pública ou privada com destinação social, conforme definir o Juízo das Execuções Criminais.

Diante da substituição, resulta prejudicada a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Indenização mínima

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conforme art. 387 do CPP, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o réu WELLINGTON RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão; e 185 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

substituída, a pena corporal, por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, §4º, do CP); e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo (art. 45, §1º, do CP), em favor de entidade pública ou privada com destinação social, conforme definir o Juízo das Execuções Criminais;

b) CONDENAR o réu MICK WELLINGTON DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão; e 194 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; substituída, a pena corporal, por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, §4º, do CP); e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo (art. 45, §1º, do CP), em favor de entidade pública ou privada com destinação social, conforme definir o Juízo das Execuções Criminais;

Na hipótese de descumprimento injustificado (art. 44, § 4º do Código Penal), deverão os réus iniciarem o cumprimento da pena corporal no regime ABERTO (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

"Status Libertatis": Em razão da pena aplicada e substituída, não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Portanto, os réus poderão recorrer em liberdade. Desnecessária, ainda, a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, motivo pelo qual as revogo. Expeça-se alvará de soltura clausulado/contramandado.

Disposições finais

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Transitada em julgado:

a) Expeçam-se as guias de execução definitiva;

b) Proceda-se à atualização do valor da multa, intimando-se os réus para pagamento em 10 dias, nos termos dos arts. 49, §2º, 50 e 51 do CP e 164 da LEP;

c) Oficie-se ao IIRGD;

d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos dos réus, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Oficie-se ao Ministério Público, para apuração de eventual delito de falso testemunho pela testemunha Paulo César Domingues (art. 40 do CPP).

Expeçam-se as certidões aos Defensores Dativos, se o caso, conforme valores e termos do Convênio OAB/Defensoria.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA